

1513568-72.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de tráfico, diante de reincidência do acusado que há tempos se dedica a atividades criminosas, já que ao ser solto, após cumprir pena por vários delitos, dentre eles inclusive tráfico de entorpecentes, novamente voltou a delinquir, o que demonstra que não faz jus ao benefício.

Diante do exposto, julgo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1513568-72.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513568-72.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS PRATES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

VINICIUS PRATES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, segundo apurado no incluso inquérito policial que no dia 02 de junho de 2021, por volta das 18h42min, na Rua Bento Freitas, 34 - República, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 19 (dezenove) porções individuais de cocaína (massa líquida: 17,5g), droga capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, apresentando resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução foram ouvidos dois policiais e o réu foi interrogado.

Em face das alegações do acusado a Defesa solicitou antes do encerramento da instrução, a " expedição de ofício à Polícia Militar requisitando as imagens das câmeras operacionais portáteis dos policiais referentes ao dia da prisão. (fls. 128/129).

Tal diligência fez com que os autos permanecessem com andamento suspenso, até que a Defesa conseguisse ter o acesso às filmagens consoante petições de fls.149/150 e 155/158.

Após a diligência ser concluída, as partes foram intimadas para apresentação de

suas alegações finais.

Em suas alegações escritas o Ministério Público pugnou, em suma, pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.(fls. 164/168).

A Defesa por sua vez, buscou a absolvição do réu por insuficiência probatória para a condenação.

Subsidiariamente, e em caso de eventual condenação requereu a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de entorpecentes e a absolvição pela atipicidade da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, ou ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, e estabelecimento de regime diverso do fechado para o cumprimento de sua pena e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante as alegações da Defesa, analisando as provas colhidas nos autos, há provas suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão das drogas, laudo pericial com resultado POSITIVO para cocaína. (fls. 131/133).

A autoria também é inconteste.

Com efeito, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, os dois policiais ouvidos em juízo afirmaram que após receberem denúncia anônima no sentido de que o havia um indivíduo comercializando drogas no local indicado e de posse das características dessa pessoa, se dirigiram ao local narrado e fizeram a apreensão do réu, que além de ter as características mencionadas foi encontrado com aproximadamente 20 porções de drogas.

Os dois afirmaram, ainda que o réu era procurado pela polícia e que havia outras pessoas no local no momento em que o réu foi abordado.

O réu por sua vez, ao ser interrogado em juízo, disse que estava foragido do sistema prisional pois é usuário de drogas e acabou contraindo uma dívida de drogas dentro da cadeia e como não tinha como pagar, temia por sua segurança.

Afirmou que no dia dos fatos estava vindo da casa de sua irmã e parou na Estação da Luz, local conhecido como sendo de comércio de tráfico de entorpecentes, para adquirir drogas e que ao sair dali, foi abordado pelos policiais e de pronto confirmou que trazia consigo drogas apenas para seu consumo próprio, alegando, ainda, que estava foragido da Justiça.

Consignou, ainda, que toda sua prisão foi gravada nas câmeras dos policiais e por isso solicitou que elas fossem juntadas aos autos.

Pois bem, diante das alegações do réu a Defesa conseguiu juntar aos autos as imagens obtidas após o acesso às câmeras que estavam acopladas aos policiais, nas quais se verifica apenas o momento em que o acusado é colocado dentro da viatura da polícia.

Ora, tais documentos, para esta magistrada, ao contrário do que quis fazer crer a Defesa, em nada maculam as versões apresentadas pelos policiais. Não as confirmam de fato, mas também não as desconfiguram.

Desta feita, caberia a Defesa, de posse de tais filmagens, ser mais específica em relatar quantas horas há de gravação, qual a primeira abordagem policial foi gravada, a qual dos dois policiais pertencia a câmera, de cuja imagem foi por ela juntada, ou seja, provas concretas de que há nos autos somente essas imagens do réu e que não foi realizado o procedimento de gravação de toda conduta policial, apesar das câmeras estarem ligadas.

Consigne-se, que a Defesa, teve acesso as imagens e o fato de não poder ser feito o "download" de todo o conteúdo, em nada a prejudicou já que foi possível a juntada nos autos das imagens, por meio de "prints".

Por outro lado, o réu sequer trouxe aos autos o endereço ou mesmo a qualificação de sua irmã que poderia ser ouvida para se o caso confirmar sua versão.

Assim o que temos de concreto nos autos é que negativa do réu não é crível e não vem amparada por quaisquer outros elementos de convicção e em contrapartida, os depoimentos dos policiais convergem em mesmo sentido e os dois foram uníssomos em afirmar, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos que apreenderam o réu em local conhecido como sendo ponto de tráfico, trazendo consigo, várias porções de

drogas.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas. Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, muito embora tenha a il. defesa tentado caracterizar de tal forma.

Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento que realizavam pela região conhecida como sendo ponto de venda de drogas. sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação ao acusado. Nesse sentido: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Ressalta-se, ademais que a quantidade de drogas apreendidas, pelos policiais, sua forma de acondicionamento, o local em que o réu estava, já conhecido por todos como sendo ponto de venda de drogas, bem como o dinheiro, com ele encontrados, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Diante deste contexto e ainda porque, o réu não trouxe aos autos provas de que as drogas com ele encontradas eram apenas para seu uso próprio, não sabendo ainda esclarecer o motivo pelo qual foram apreendidas bem mais que 05 ou 04 porções que segundo ele realmente lhe pertenciam, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, e tem inúmeras outras condenações, consoante se depreende da certidão de fls. 39/43.

Assim sendo a condenação definitiva decorrente dos autos nº 1514152-13.2019.8.26.0228, que tramitou perante a 28ª Vara Criminal Central, (fls. 40), será tida como agravante e devidamente analisada na segunda fase de aplicação de pena.

As demais, (autos nºs 0017316-61.2009.8.26.0050, 0058836-83.2018.8.26.0050; 0091156-02.2012.8.26.0050) serão consideradas como maus antecedentes, e nos permitem, nos termos do disposto no art. 59 do CP aumentar a pena base em 1/4, chegando-se a 6 anos, 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Apenas a título de argumentação, não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, sob pena de se ferir de morte o princípio da individualização da pena.

De fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa

do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- “condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes” (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, “não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência” (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

“Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, há que se considerar a reincidência acima citada, bem como que o crime foi cometido em meio à pandemia da COVID 19, em época em que as restrições governamentais ainda estavam vigentes e de maneira mais severa.

Com efeito, para esta magistrada, respeitado posicionamento em contrário, não há de afastar a agravante do art. 61, inc. II, alínea “j”, do Código Penal, já que como apontado o crime ocorreu durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, já que estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP – PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

“(…) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o

criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

E ainda:

“O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda. (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), “a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Não se exige na linha do que penso – que o agente que se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

Desse modo a pena deve ser agravada em mais 1/5, chegando-se a 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na terceira fase, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de tráfico, diante de reincidência do acusado que há tempos se dedica a atividades criminosas, já que ao ser solto, após cumprir pena por vários delitos, dentre eles inclusive tráfico de entorpecentes, novamente voltou a delinquir, o que demonstra que não faz jus ao benefício.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para CONDENÁ-LO à pena de 07 anos, 06 meses de reclusão e ao pagamento de 750 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como diante da reincidência atestada nos autos e ainda em razão dos maus antecedentes certificados, o réu cumprirá a pena em regime inicial fechado.

Em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou. Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), Destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos

ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, já que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos.

Diante disso, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a decisão que determinou sua prisão preventiva.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06.

Determino ainda a destruição das drogas apreendidas, inclusive material reservado para contra-prova. Oficie-se neste sentido.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA